

## 서울중앙지법 2025. 5. 1. 선고 2023가합96954 판결 : 항소

【해고무효확인】 , [각공2025하,317]

### 【판시사항】

홈쇼핑 사업 등을 영위하는 갑 주식회사와 쇼핑호스트 업무 위촉계약을 체결하고 프리랜서 쇼핑호스트로 활동한 을이 근로기준법에 따른 근로자에 해당하는지 문제 된 사안에서, 갑 회사가 쇼핑호스트의 업무수행에 대하여 구체적이고 직접적인 지휘·감독을 한다고 할 수 없는 점 등 제반 사정에 비추어 을을 갑 회사의 근로자라고 보기 어렵다고 한 사례

### 【판결요지】

홈쇼핑 사업 등을 영위하는 갑 주식회사와 쇼핑호스트 업무 위촉계약을 체결하고 프리랜서 쇼핑호스트로 활동한 을이 근로기준법에 따른 근로자에 해당하는지 문제 된 사안이다.

① 쇼핑호스트의 방송 업무 자체는 쇼핑호스트가 개인적인 역량을 발휘하여 자율적으로 수행하는 것으로서 정형화된 업무 수행 방법이 있을 수 없는 등 갑 회사가 쇼핑호스트의 업무 수행에 대하여 구체적이고 직접적인 지휘·감독을 한다고 할 수 없는 점, ② 쇼핑호스트에 대해서는 고정된 출퇴근시간이나 월 소정근로시간 등이 정해져 있지 않았고, 자유롭게 개인일정을 사용할 수 있었으며, 자신에게 배정된 방송 일정 수락 여부를 결정할 수 있었을 뿐만 아니라 방송이나 방송 준비, 회의 외에는 시간과 장소의 제약 없이 업무를 수행할 수 있었으므로, 근무시간과 장소의 지정이 있었다고 볼 수 없는 점, ③ 쇼핑호스트는 취업규칙의 적용을 받지 않았고, 위촉계약에는 근로시간, 연차 유급휴가 등 근로기준법 제17조 에 따라 근로조건으로 명시되어야 하는 사항이 충분히 정해져 있지 않았으며, 쇼핑호스트에 대하여는 근로소득세가 아닌 사업소득세를 원천징수하였고 4대 보험의 가입대상자도 아니었던 점, ④ 쇼핑호스트는 위촉계약에 따라 방송 횟수 및 출연 시간에 비례한 수수료만 받을 뿐 기본급이나 고정급이 없었고, 쇼핑호스트가 지급받은 수수료를 노무 제공에 따라 고정적으로 지급받는 것으로서 근로 자체의 대상적 성격을 가진 것이라고 보기 어려운 점, ⑤ 위촉계약에 전속적 요소가 있다는 것만으로 을이 종속적 관계에서 갑 회사에 노무를 제공하는 근로자라고 볼 수는 없고, 쇼핑호스트는 계약기간이 종료되면 자유롭게 다른 홈쇼핑과 위촉계약을 체결할 수 있었으며, 을에게 근로관계의 체결, 유지 및 종료에 관한 충분한 선택권이 보장되었던 점 등 제반 사정에 비추어 을을 갑 회사의 근로자라고 보기 어렵다고 한 사례이다.

### 【참조조문】

근로기준법 제2조 제1항 제1호 , 제17조

## 【전문】

【원 고】 원고 (소송대리인 법무법인 수안 담당변호사 하헌웅)

【피 고】 주식회사 ○○○리테일 (소송대리인 법무법인 이제 담당변호사 김관하 외 1인)

## 【주문】

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

## 【취지】

피고가 원고에 대하여 한 2023. 7. 27. 자 해고는 무효임을 확인한다.

## 【변론종결】

2025. 2. 6.

## 【이유】

### 1. 기초 사실

#### 가. 당사자들의 지위

1) 피고는 체인화 편의점, 마트, 전자상거래 등 사업을 영위하는 회사이고, 2021. 7. 1. 주식회사 ○○○홈쇼핑 (이하 ‘△△홈쇼핑’이라 한다)을 흡수합병한 이후 홈쇼핑 사업도 영위하고 있다.

2) 원고는 2005. 5.경 ‘△△쇼핑호스트 선발대회’를 통하여 △△홈쇼핑과 근로계약을 체결하고 쇼핑호스트로 활동하다가, 퇴직원을 제출하여 가입기간에 상응하는 퇴직연금을 지급받은 후, 2017년경부터는 ‘쇼핑호스트 업무 위촉계약서’를 기초로 한 쇼핑호스트 업무 위촉계약을 체결하고 2023. 7. 31.까지 △△홈쇼핑에서 쇼핑호스트로 활동한 사람이다.

#### 나. 쇼핑호스트 업무 위촉계약의 내용

원고와 피고는 2017. 1. 1.경 계약기간을 2017. 1. 1.부터 2019. 12. 31.까지로 하여 위와 같이 쇼핑호스트 업무 위촉계약을 체결하였고, 2020. 1. 1.경 계약기간을 2020. 1. 1.부터 2022. 12. 31.까지로 하여 같은 내용의 계약을 다시 체결하였으며, 2023. 2. 1.경 계약기간을 2023. 2. 1.부터 2025. 1. 31.까지로 하여 같은 내용의 계약을 다시 체결하였다(이하 위 각 계약을 ‘이 사건 위촉계약’이라 하고, 이 사건 위촉계약 체결 시 작성한 ‘쇼핑호스트 업무 위촉계약서’의 주요 내용은 아래와 같다).

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 피고와 원고는 다음과 같이 프리랜서 쇼핑호스트 업무 위촉계약(이하 ‘본 계약’이라 함)을 체결하고 이의 성실한 준수를 약정한다. |
|-------------------------------------------------------------------------|

|             |
|-------------|
| 제1조(계약의 목적) |
|-------------|

|                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 본 계약은 피고가 운영하는 상품 판매 채널(생방송, 데이터방송, 모바일, VOD, 각종 사전제작 및 제휴채널)(이하 ‘매장’이라고 함)에서 원고의 쇼핑호스트 업무(이하 ‘업무’라 함)를 성실히 수행함에 있어 필요한 피고와 원고의 권리와 의무를 명확히 함을 목적으로 한다.                                  |
| 제2조(업무 범위 및 방법)                                                                                                                                                                          |
| 1. 본 계약에 따라 원고는 다음 각호에 규정된 업무를 성실히 수행하여야 한다.                                                                                                                                             |
| ① 사전미팅 참석: 상품 내용 및 방송 판매 기획 숙지                                                                                                                                                           |
| ② 피고의 연출 기획에 맞는 방송 프로그램 쇼핑호스트 업무                                                                                                                                                         |
| ③ 기타 피고가 업무와 관련하여 별도로 요청하는 사항                                                                                                                                                            |
| 2. 피고와 원고는 상호 협의에 따라 원고의 구체적인 업무 수행 일자 또는 방송 프로그램 출연일자를 정한다(일정 변경 포함). 단, 원고는 자신의 개인적인 사유로 방송 프로그램 출연일자 변경이 필요할 경우 방송 프로그램의 제작 또는 방송 일정을 고려하여 방송일 기준 최소 2주일 전에 피고에게 통지하여 피고의 동의를 받아야 한다. |
| 제4조(수수료)                                                                                                                                                                                 |
| 1. 피고는 원고가 계약상 업무를 수행한 대가로 수수료를 지급하기로 하며, 지급기준은 다음 각호와 같다.                                                                                                                               |
| ① TV홈쇼핑(케이블 TV 홈쇼핑, 위성방송, IPTV 등 포함 / 이하 ‘TV홈쇼핑’이라 함) 생방송 또는 녹화방송 출연 시: 1시간당 삼십오만 원(W350,000)                                                                                            |
| ② 각종 사전 제작물(데이터홈쇼핑 녹화물, TV홈쇼핑용 인서트 등 포함 / 이하 ‘사전 제작물’이라 함)의 촬영 시 수수료 기준은 다음 각 목과 같다.                                                                                                     |
| 가. 1일 총촬영시간 4시간 이하일 경우: TV홈쇼핑 생방송 1시간 수수료                                                                                                                                                |
| 나. 1일 총촬영시간 4시간 초과일 경우: TV홈쇼핑 생방송 1시간 30분 수수료                                                                                                                                            |
| ③ TV홈쇼핑 생방송 또는 녹화방송의 재방송 출연 시 수수료 기준은 다음과 같다.                                                                                                                                            |
| 가. 해당 생방송 또는 녹화방송의 재방송 시 1회에 한하여 해당 방송의 본 방송 수수료의 20%에 해당하는 금액                                                                                                                           |
| ④ 원고가 본 계약상 업무의 수행을 위하여 출장 시 수수료 기준은 다음 각 목과 같다.                                                                                                                                         |
| 가. 국내출장 시: 본 항 제2호의 기준과 동일                                                                                                                                                               |
| 나. 해외출장 시: TV홈쇼핑 생방송 1시간 30분 수수료 × 숙박일                                                                                                                                                   |
| 2. 피고는 매월 해당 월 1일부터 말일까지 발생한 수수료를 정산하여 익월 3일 이내에 원고에게 현금 지급하기로 하며, 제 세금은 원고가 부담한다.                                                                                                       |
| 3. 본 계약을 위반하여 원고의 피고에 대한 손해배상금, 위약금 등의 지급의무가 발생한 경우, 피고는 원고가 손해배상금, 위약금 등을 완전히 변제할 때까지 수수료 지급을 보류하거나 상계 후 지급할 수 있다                                                                       |
| 제7조(업무상 준수 사항)                                                                                                                                                                           |
| 1. 원고는 다음 각호에 정한 사항을 준수하여야 하며, 위반 시 본 계약이 해지될 수 있음을 확인한다.                                                                                                                                |
| ① 원고는 쇼핑호스트의 이미지가 피고 또는 피고의 브랜드 이미지와 연결되어 소비자들에게 받아들여지는 홈쇼핑 업체의 특성을 고려하여, 본 계약기간 동안 다음 각 목에 정한 사항을 수행할 수 없으며, 본 항은 계약의 해지 또는 종료 이후 1개월 동안 유효하다.                                          |
| 가. 타 홈쇼핑 및 유사 홈쇼핑 등 방송을 통한 유통업체(이하 통칭하여 ‘경쟁업체’라 함)에 출연하는 행위                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 나. ‘경쟁업체’의 인터넷, 잡지 등의 광고 모델로 출연하는 행위                                                                                                                                                                         |
| 다. ‘경쟁업체’가 주최 또는 주관하는 각종 행사나 이벤트에 참여하는 행위                                                                                                                                                                    |
| 라. ‘경쟁업체’에 원고의 저작권, 성명·초상권을 제공하는 등 각종 캐릭터를 이용하여 참여하는 행위                                                                                                                                                      |
| ② 원고는 ‘경쟁업체’를 포함한 제3자와 본 계약과 동일하거나 유사한 내용의 계약 체결로 인해 피고의 방송 프로그램에 출연하는 데 장애가 생기지 않도록 한다.                                                                                                                     |
| 2. 원고는 자신이 방송 프로그램 출연 시 제공하는 각종 정보가 방송통신위원회·공정거래위원회 등 관련 행정기관에서 정한 심의 규정 및 표시·광고의 공정화에 관한 법률 등 관련 법령에 위배되지 않도록 주의하여야 한다. 만일 방송 프로그램 출연 시 임의로 멘트를 하여 심의 제재가 발생할 경우 제재 결과에 따라 일정기간 방송 프로그램 출연이 정지될 수 있음을 확인한다. |
| 3. 원고는 자신의 적절하지 않은 개인적 언행 등(온·오프라인 동호회, SNS, 블로그 활동 포함)으로 인하여 피고 또는 피고의 임직원의 명예나 신용이 훼손될 수 있음을 인지하고 이에 대한 주의의무를 다하기로 한다. 만일 이를 위반할 경우 방송 프로그램 출연이 정지되거나 본 계약이 해지될 수 있음을 확인한다.                                |
| 4. 원고는 피고의 사전 동의 없이 다음 각호의 행위를 할 경우(피고가 사전 동의한 사실과 다를 경우 포함) 방송 프로그램 출연이 정지되거나 본 계약이 해지될 수 있음을 확인한다.                                                                                                         |
| ① 방송 프로그램 출연에 영향을 미치지 아니하는 강의 또는 집필 행위                                                                                                                                                                       |
| ② 각종 대중 매체 출연 및 인터뷰 행위                                                                                                                                                                                       |
| ③ 각종 기업 및 제품의 모델 활동(단, ‘경쟁업체’의 모델 활동은 제외)                                                                                                                                                                    |
| 5. 원고는 다음 각호의 행위를 할 경우 방송 프로그램 출연이 정지되거나 본 계약이 해지될 수 있음을 확인한다.                                                                                                                                               |
| ① 피고와 사전 협의한 방송 프로그램 미출연 또는 출연 일정 변경 사유가 허위일 경우(허위 증빙자료 제출 등)                                                                                                                                                |
| ② 피고와 사전 협의 없이 또는 정당한 사유 없이 2회 이상 방송 프로그램 출연 일정을 미준수하거나 출연을 거부할 경우                                                                                                                                           |
| 제10조(계약의 해지)                                                                                                                                                                                                 |
| 1. 피고와 원고는 상호 서면 합의에 따라 본 계약을 해지할 수 있으나 제7조 제1항 제1호의 효력은 유효하다.                                                                                                                                               |
| 2. 피고는 원고에게 다음 각호의 사유가 발생한 경우 10일 전 서면 통지로서 본 계약을 해지할 수 있다.                                                                                                                                                  |
| ① 제7조에 정한 계약 해지 사유에 해당할 경우                                                                                                                                                                                   |
| ② 정당한 사유 없이 본 계약을 이행하지 않거나 해태하는 경우                                                                                                                                                                           |
| ③ 피고의 임직원, 협력사 또는 방송 관련자(게스트, 모델 등)들과 불미스러운 문제를 야기하여 본 계약상 업무에 지장을 초래하거나 피고나 피고의 브랜드 이미지 또는 피고가 소개·판매하는 상품의 이미지를 실추시킬 우려가 있다고 피고가 판단하는 경우                                                                    |
| ④ 관련 법령을 위반하는 행위나 사회적 물의를 일으키는 행위로 인하여 피고나 피고의 브랜드 이미지 또는 피고가 판매하고자 하는 상품의 이미지를 실추시킬 우려가 있다고 피고가 판단하는 경우                                                                                                     |
| ⑤ 제3자로부터 원고를 상대로 민형사상 청구가 제기되어 본 계약의 이행에 차질이 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우                                                                                                                                             |
| ⑥ 제8조(비밀유지)를 위반할 경우                                                                                                                                                                                          |
| ⑦ 기타 원고가 쇼핑호스트로서 활동할 수 없다고 객관적으로 판단되는 경우                                                                                                                                                                     |
| 3. 원고는 피고가 정당한 사유 없이 지급이 확정된 수수료를 2개월 이상 연속하여 지급하지 않는 경우                                                                                                                                                     |

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| 10일 이전 서면 통지으로써 본 계약을 해지할 수 있다.                             |
| 4. 본 계약의 해지는 손해배상청구권 등 이미 발생한 피고와 원고의 권리와 의무에 영향을 미치지 아니한다. |

다. 이 사건 위촉계약의 종료

피고는 2023. 6. 28.경 언론사로부터 쇼핑호스트 갑질 및 폭언에 관한 문의를 받은 후 이에 대한 조사를 진행하였고, 2023. 7.경 원고의 후배에 대한 폭언 등을 이유로 원고에 대한 출연 정지 조치를 하였다. 그 후 피고는 2023. 7. 31. 원고의 계약해지 요청에 따른 계약해지 형태로 이 사건 위촉계약을 종료하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5호증, 을 제1, 6 내지 17, 28 내지 30, 61호증(가치번호 있는 것은 각 가치번호 포함, 이하 같다)의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 청구원인에 관한 판단

가. 원고의 주장 요지 주1)

원고는 △△홈쇼핑 에 입사하여 임금을 목적으로 종속적인 관계에서 △△홈쇼핑 으로부터 상당한 지휘·감독을 받으면서 쇼핑호스트 업무를 수행하였는데, △△홈쇼핑 이 일방적으로 쇼핑호스트를 프리랜서로 전환시킨 이후에도 쇼핑호스트의 업무 수행 방식은 종전과 거의 동일하였으므로(이는 피고가 △△홈쇼핑 을 흡수합병한 이후에도 마찬가지이다), 원고는 피고의 근로자로서 업무를 수행하였다고 보아야 한다. 따라서 피고가 2023. 7. 31. 이 사건 위촉계약을 종료한 것은 원고에 대한 해고로 보아야 하는데, 피고는 근로기준법 제27조 제1항에 따른 해고사유 등의 서면통지의무를 이행하지 아니하였고, 근로기준법 제23조 제1항 에서 정하는 정당한 이유도 없으므로, 원고에 대한 해고는 절차적·실체적으로 하자가 있어 무효이다.

나. 판단

1) 관련 법리

가) 근로기준법에 따른 근로자에 해당하는지는 계약의 형식이 고용계약인지 도급계약인지보다 그 실질이 근로자가 사용자에 대한 종속적 관계에서 임금을 목적으로 사용자에게 근로를 제공하였는지 여부에 따라 판단하여야 한다. 여기에서 종속적인 관계가 있는지는 업무 내용을 사용자가 정하고 취업규칙 또는 복무(인사)규정 등이 적용되며 업무 수행 과정에서 사용자가 지휘·감독을 하는지, 사용자가 근무 시간·장소를 지정하고 근로자가 이에 구속되는지, 노무제공자가 스스로 비품·원자재나 작업도구를 소유하거나 제3자를 고용하여 업무를 대행하도록 하는 등 독립하여 자신의 계산으로 사업을 영위할 수 있는지, 노무 제공을 통해 스스로 이윤을 창출하거나 손실 등 위험을 부담하는지, 보수의 성격이 근로 자체의 대상적 성격인지, 기본급이나 고정급이 정해져 있는지, 근로소득세를 원천징수하는지 등 보수에 관한 사항, 근로 제공 관계의 계속성과 사용자에 대한 전속성의 유무와 그 정도, 사회보장제도에 관한 법령에서 근로자로 인정되는지 등 경제적·사회적 여러 조건을 종합하여 판단하여야 한다( 대법원 2006. 12. 7. 선고 2004다29736 판결 , 대법원 2018. 10. 25. 선고 2015두51460 판결 등 참조).

나) 근로기준법의 적용을 받는 근로자에 해당하는지 여부는 계약의 형식에 관계없이 그 실질에 있어서 임금을 목적으로 종속적인 관계에서 사용자에게 근로를 제공하였는지 여부에 따라 판단하여야 할 것이며, 그에 대한 입증책임은 근로자임을 주장하는 자에게 있다 할 것이다( 대법원 2006. 11. 9. 선고 2006다54637, 54644 판결 등 참조).

2) 구체적 판단

앞서 든 각 증거, 을 제36, 37, 39, 40, 44, 56 내지 59호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정을 위 법리에 비추어 보면 원고를 피고의 근로자라고 보기 어려우므로, 원고의 주장은 이유 없다.

가) 피고 소속 쇼핑호스트의 종류

피고에는 ① 출퇴근 시간과 소정 근로시간이 정해져 있고 피고 취업규칙 등 피고 내부규정의 적용을 받는 전문계약직 쇼핑호스트와 ② ‘프리랜서 쇼핑호스트 업무 위촉계약서’를 작성하여 이 사건 위촉계약과 같은 내용의 계약을 체결하고 쇼핑호스트 업무를 수행하는 프리랜서 쇼핑호스트(원고가 여기에 포함된다)가 있다. 이하에서는 프리랜서 쇼핑호스트를 기준으로 판단한다(이하 ‘쇼핑호스트’ 기재는 ‘프리랜서 쇼핑호스트’를 의미하



고, 특정이 필요한 경우에만 전문계약직 또는 프리랜서 쇼핑호스트를 특정한다).

나) 구체적인 업무 수행이 피고의 지시대로 이루어지는지 여부

(1) 쇼핑호스트는 방송 3~5일 전에 담당 PD·MD, 협력업체 관계자 등과 함께 회의에 참석하여 판매할 상품의 특징에 관한 설명을 듣고, 상품의 특징과 방송에서의 표현 등을 함께 논의한 후 이를 기초로 하여 개인의 설명 방식이나 요령에 따라 방송을 진행하면서 상품을 설명하고 시연하게 된다.

(2) 이처럼 쇼핑호스트의 주요한 업무인 방송 업무가 피고가 주도한 위 회의에서 정한 기본적인 방향과 기획 의도에 따르는 제약이 있기는 하나, ① 이 사건 위촉계약서 제2조 제1항 제1호는 「본 계약에 따라 원고는 다음 각호에 규정된 업무를 성실히 수행하여야 한다. 사전미팅 참석: 상품 내용 및 방송 판매 기획 숙지」를 정하고 있으므로, 원고가 방송을 위하여 피고가 진행하는 회의에 참석하는 것은 계약에서 정한 사항을 이행하는 것으로 볼 수 있는 점, ② 다른 방송과 달리 피고는 쇼핑호스트에게 방송 대본을 주지 않는 점, ③ 쇼핑호스트의 방송 업무 자체는 쇼핑호스트가 개인적인 역량을 발휘하여 자율적으로 수행하는 것으로서 정형화된 업무 수행 방법이 있을 수 없는 점 등에 비추어 보면, 피고가 쇼핑호스트의 업무 수행에 대하여 구체적이고 직접적인 지휘·감독을 한다고 할 수 없다.

(3) ① 피고가 행사를 개최하는 경우 전문계약직 쇼핑호스트에게 행사 사회 등 지원업무를 지시하지만, 필요한 경우 프리랜서 쇼핑호스트들에게 행사진행을 요청하였고, ② 쇼핑호스트가 방송통신심의위원회 소위원회 방청교육에 참석하거나 ③ 신입 쇼핑호스트들의 조장이나 멘토 등 업무를 수행하기도 하였으나, 쇼핑호스트로서는 이를 거절하는 등 자유롭게 위 각 업무의 수행 여부를 선택할 수 있었고, 위 각 업무를 수행하는 경우 그에 대한 수수료가 지급되었다. 또한 위 각 업무는 이 사건 위촉계약서 제2조 제1항 제3호의 「기타 피고가 업무와 관련하여 별도로 요청하는 사항」에 해당한다고 보아야 하므로, 원고가 이 사건 위촉계약에 따라 위 각 업무를 수행한 것이 피고의 근로자로서 피고의 구속력 있는 지시에 따른 것이라고 볼 수도 없다.

다) 원고의 근무형태(근무시간, 근무장소 등) 및 피고의 근무관리

(1) 쇼핑호스트에 대해서는 고정된 출퇴근시간이나 월 소정근로시간 등이 정해져 있지 않았고, 쇼핑호스트의 출퇴근시간을 관리·감독하는 전산시스템이나 그 내역을 기재하여 제출하게 하는 업무절차도 없었다. 따라서 쇼핑호스트는 홈쇼핑 방송 준비 및 촬영, 방송 후 리뷰, 정리 등을 위해 필요한 ‘방송업무시간(방송녹화 시작 2시간 전~방송종료 후 1시간)’의 준수만 요구되었다. 피고는 여성 쇼핑호스트에게 ‘녹화(생방송) 2시간 전’까지, 남성 쇼핑호스트에게 ‘녹화(생방송) 1시간 30분 전까지’ 분장실로 도착할 것을 요청하였으나, 쇼핑호스트의 주된 업무인 방송 출연은 독자적으로 수행할 수 있는 것이 아니고 피고가 주관하는 방송과 함께 이루어지는 것이라는 특성을 고려하면, 위와 같은 방송 전후 일정한 시간 동안 업무가 강제되는 것은 이 사건 위촉계약에 따른 업무 수행의 일환으로 보아야 하므로, 위 사정만으로 원고에 대한 근무시간 지정이나 근무관리가 이루어진 것이라고 할 수 없다.

(2) 같은 취지에서, 방송 예정이던 쇼핑호스트가 개인적인 사정으로 방송진행이 불가능해지자 피고가 원고에게 대신 방송을 진행해 달라는 부탁을 한 것이나, 피고가 원고가 참여하는 회의 일정을 잡았던 것, 피고가 태풍 등 돌발 상황으로 인해 쇼핑호스트가 방송 시간에 스튜디오에 도착하지 못하는 비상상황에 대비하여 ‘비상긴급 담당 쇼핑호스트’를 예비적으로 지정해 둔 것(실제로 ‘비상긴급 담당 쇼핑호스트’가 활용된 사례는 없다) 등은 모두 방송 업무의 특성에 따른 통상적인 업무협조요청 범위 내의 것이라고 보아야 한다(공동의 목적을 가지고 업무를 수행하는 계약관계에서 다소의 구속력이 있는 업무요청사항이 존재한다는 사정만으로 그 계약관계를 바로 근로계약관계로 볼 수는 없다).

(3) 쇼핑호스트에게는 연차 유급휴가 제도가 적용되지 않았고, 매년 개인일정(개인적 사정으로 쇼핑호스트 업무를 수행하지 않는 날로, 사실상 휴가의 기능을 가진 것으로 보인다) 60일 정도를 연속 14일까지 자유롭게 사용할 수 있었다. 쇼핑호스트가 개인일정을 사용하려면 피고의 시스템에 2주 전에 미리 등록을 하여야 하나, 이는 피고가 방송편성 계획을 수립하고 각 방송에 쇼핑호스트를 배정하기 위하여 개인일정 사용에 최소한의 제한을 둔 것에 불과하다. 피고가 일부 쇼핑호스트에게 개인일정 조정 요청을 한 사실이 인정되나, 이러한 요청은 오히려 쇼핑호스트들이 자유롭게 개인일정을 사용할 수 있었기 때문에 나타난 결과로 보인다[이 사건 위촉계약서 제2조 제2항은 「2. 피고와 원고는 상호 협의에 따라 원고의 구체적인 업무 수행 일자 또는 방송 프로그램 출연일자를 정한다(일정 변경 포함).」라고 규정하고 있으므로, 원고가 개인일정을 사용하는 것이나

피고가 원고에게 개인일정 조정을 요청하는 것 모두 이 사건 위촉계약에서 정한 업무 수행 일자 조율의 과정이라고 볼 수 있다. 또한 쇼핑호스트로서는 개인일정을 사용하려는 경우 위와 같이 피고의 시스템에 개인일정을 등록하는 것 외에 피고로부터 허가를 받는 등의 절차가 없었으므로, 쇼핑호스트는 자유롭게 개인일정을 사용할 수 있었다고 보아야 한다(반면 피고의 다른 근로자들은 피고의 인사시스템에 연차사용 품의서를 제출하여 휴가를 사용하였다).

(4) 또한 피고가 홈쇼핑 방송 일정을 정하여 쇼핑호스트에게 알려주면 쇼핑호스트가 방송에 출연하는 방식으로 업무 일정이 정해지기는 하였으나, 방송 일정 편성과 판매 상품 결정 및 상품에 맞는 쇼핑호스트를 배정하는 것은 홈쇼핑 방송 제작사인 피고가 당연히 해야 할 업무였고, 쇼핑호스트 배정 과정에서 쇼핑호스트들의 일정이 겹치거나 공백이 발생하지 않도록 쇼핑호스트들 사이의 일정을 조율하는 것도 당연히 부수되는 업무였다고 보아야 한다. 이 과정에서 쇼핑호스트는 자신에게 배정된 방송 일정 수락 여부를 결정할 수 있었으므로, 방송 배정에 따른 방송 진행이 강제되었다고 보기도 어렵다(배정받은 방송 출연에 관한 무제한적인 선택권을 보장받지 못하였다는 이유만으로 피고의 출연 지시에 쇼핑호스트들이 구속되는 관계였다고 인정할 수는 없다).

(5) 홈쇼핑 방송 촬영을 위해서는 방송설비가 갖추어진 장소에서 많은 사람이 함께 작업을 해야 하는 것이므로, 피고가 홈쇼핑 방송을 위해서 조성한 방송 장소에서 촬영을 하도록 한 것을 들어 ‘쇼핑호스트에게 근무장소를 지정한 것’이라고 보기는 어렵다. 피고는 쇼핑호스트들이 방송 준비를 할 수 있도록 공용 사무공간이나 라운지, 수면실 등을 제공하기도 하였으나 이는 업무상 편의를 위하여 제공하는 것에 불과하고, 쇼핑호스트로서는 방송이나 방송 준비, 회의 외에는 시간과 장소의 제약 없이 업무를 수행할 수 있었으므로, 근무시간과 장소의 지정이 있었다고 볼 수 없다.

라) 근로조건에 관한 사항

(1) 쇼핑호스트는 취업규칙의 적용도 받지 않았고, 이 사건 위촉계약에는 근로시간, 연차 유급휴가 등 근로기준법 제17조 에 따라 근로조건으로 명시되어야 하는 사항이 충분히 정해져 있지 않았다.

(2) 쇼핑호스트는 피고 근로자들을 대상으로 한 법정 의무교육을 받지 않았고, 근로자들에게 제공되는 주택자금·학자금·의료비·휴가비 등의 복리후생 혜택이나 심야교통비 등을 받지 아니하였다. 피고는 쇼핑호스트에게 사원증(ID카드)을 발급해 주기는 하였으나, 쇼핑호스트 외에도 게스트, 성우, 모델이나 협력업체 직원에게도 복지를 제공하고 출입과 구내식당 이용을 위한 ID카드를 발급해 주었으므로, 원고가 위와 같은 혜택을 받은 것만으로는 원고가 피고의 근로자라고 인정하기에 부족하다.

(3) 쇼핑호스트에 대하여는 근로소득세가 아닌 사업소득세를 원천징수하였고, 4대 보험(고용보험·산재보험·국민연금·건강보험)의 가입대상자도 아니었다.

(4) 쇼핑호스트 업무규정, 방송운영 업무규정, 체험용 샘플 사용 프로세스 등은 쇼핑호스트가 위임계약의 성질을 가지는 이 사건 위촉계약에 따라 업무를 수행하면서 지켜야 할 사항에 불과하고, 위 가이드 등이 업무를 처리함에 있어 요구되는 준수사항을 넘어 근로관계에 적용되는 통상적인 취업규칙이나 복무(인사)규정에 해당한다고 보기는 어렵다.

마) 원고가 지급받은 수수료의 성격 및 기본급의 유무 등

(1) 쇼핑호스트는 이 사건 위촉계약에 따라 방송 횟수 및 출연 시간에 비례한 수수료만 받을 뿐 피고의 급여·상여지급규정에 따른 고정 급여를 받지 않았으므로, 기본급이나 고정급이 없었다. 이 사건 위촉계약서 제4조(수수료)는 쇼핑호스트에게 지급하는 수수료의 지급기준을 방송 횟수 및 시간으로 정하고 있는데, 이러한 수수료 지급 구조는 쇼핑호스트의 업무의 특성이 반영된 것으로서, 쇼핑호스트는 높은 판매실적, 인기도 등을 갖추는 경우 더 많은 방송을 배정받을 수 있어서 더 높은 수입을 얻는 것이 가능하였고, 이에 따라 각 쇼핑호스트의 ‘수수료 산정기준(시간당 수수료액)’도 차이가 발생하게 되었다.

(2) 결국 쇼핑호스트가 받는 수수료는 개인적 역량이나 고객 선호도·인기도 등이 직접적으로 반영된 것으로서, 쇼핑호스트가 지급받은 수수료를 노무 제공에 따라 고정적으로 지급받는 것으로서 근로 자체의 대상적 성격을 가진 것이라고 보기는 어렵다.

바) 원고의 피고에 대한 전속성

(1) 이 사건 위촉계약서 제7조는 원고가 경쟁업체의 모델로 출연하거나 경쟁업체의 행사나 이벤트에 참여하는

행위를 금지하고 있고, 기타 외부활동의 경우에도 사전에 피고의 동의를 얻도록 하는 등 원고의 피고에 대한 전속적 요소들이 인정되기는 한다. 그러나 이러한 전속적 요소는 방송에 출연하는 쇼핑호스트의 이미지가 피고의 홈쇼핑 브랜드와 직결되어 소비자들에게 각인되는 특수성에 기인한 것이어서, 이 사건 위촉계약에 전속적 요소가 있다는 것만으로 원고가 종속적 관계에서 피고에게 노무를 제공하는 근로자라고 볼 수는 없다.

(2) 이 사건 위촉계약은 3년 단위로 기간을 정하여 체결되었는데, 원고와 같은 쇼핑호스트는 계약기간의 종료로 계약관계가 종료되면 자유롭게 다른 홈쇼핑과 위촉계약을 체결하여 계약관계에서 벗어날 수 있었고, 계약기간 종료 전에도 피고와 협의하여 계약관계를 종료할 수 있었다. 주2) 실제로 원고는 2022. 12. 31. 이 사건 위촉계약 기간이 종료되자 본인의 의사로 재위촉계약을 체결하지 않았다가, 다시 피고에게 재계약 의사를 전달하고, 피고가 이를 받아들여 2023. 2. 1.경 다시 이 사건 위촉계약을 체결하기도 하였는데, 이러한 형태의 계약 해지 및 재계약은 원고에게 근로관계의 체결, 유지 및 종료에 관한 충분한 선택권이 보장되었기 때문인 것으로 볼 수 있다.

### 3. 결론

따라서 원고가 피고의 근로자임을 전제로, 피고가 근로기준법 제27조 제1항, 제23조 제1항을 위반하였다는 원고의 주장은 이유 없다.

그렇다면 원고의 청구는 이유 없으므로 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

## 판사 정희일(재판장) 박승균 이영주

주1) 원고와 피고는 이 사건 위촉계약의 합의해지 여부도 다투었으나, 원고의 전체적인 주장 취지가 ‘원고의 근로자성이 인정되지 아니하는 경우, 위임계약으로서 이 사건 위촉계약이 여전히 유효하게 존속한다는 확인을 구한다.’는 것은 아닌 점, 이 사건 변론종결 당시 이 사건 위촉계약 종료일인 2025. 1. 31.이 경과한 점 등을 고려하여, 합의해지 여부에 관해서는 판단하지 아니한다.

주2) 이 사건 위촉계약서 제10조(계약의 해지) 제1항